

الدكتور بي أحمد موله

أستاذ القانون الجنائي بجامعة العلوم الإسلامية بلعبيون

تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في التشريع الموريتاني والمقارن

Raising a public lawsuit by the Public Prosecution in the Mauritanian and Tunisian legislations

ملخص:

من المبادئ السائدة في التشريعات الجنائية المعاصرة أنه "لا عقوبة بدون محاكمة" ومعنى ذلك أنه لا يجوز للدولة اللجوء إلى تنفيذ العقاب مباشرة وإنما عليها أن تستصدر حكما قضائيا يكشف حقها ويقضي بنفاذه بعد ثبوته.

فحق الدولة في العقاب يمر بعدة مراحل إجرائية تبتدئ بالبحث في الجرائم وجمع الأدلة وتنتهي بإصدار حكم إما بالبراءة أو بالإدانة وتنفيذ الحكم.

والطريق إلى ذلك يمر حتما بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وقد أعطى كل من التشريعين الموريتاني والتونسي النيابة العامة فضلا عن بعض الأطراف الأخرى حق إثارة الدعوى العمومية وفقا لما تراه ملائما، كما حددا ثلاث طرق لتحريك الدعوى العمومية تتمثل في الإحالة المباشرة على المحكمة المختصة أو طلب التحقيق أو عرض المتهم مباشرة على الجلسة في حالة التلبس، لكن التشريعين اختلفا في نطاق تلك الطرق فإذا كان المبدأ مثلا في التشريع التونسي يقضي بالزامية التحقيق في جميع الجنايات دون استثناء فإن المشرع الموريتاني لم يجعل التحقيق إلزاميا إلا في جنايات محددة أوردتها المادة 71 من ق إ ج على سبيل الحضر.

Article summary:

One of the well-established principles in contemporary criminal legislation is that "there is no penalty without trial," So the state may not implement the penalty before having a judicial sentence establishing the penalty and deciding its enforcement.

The state's right to punishment pass through several procedural stages start with the investigation of crimes and the collection of evidence, and end with the issuance of a decision either acquittal or conviction and the execution of the sentence.

These stages are accomplished through the initiation and exercise of the public lawsuit. Both the Mauritanian and Tunisian legislations give the Public Prosecution Office, in addition to the other parties, the right to initiate a public lawsuit as it deems appropriate.

Each of the two legislations specifies three methods to initiate a public lawsuit, which are (i) direct referral to the competent court, (ii) request for investigation, or (iii) presentation of the accused directly to the hearing in case of flagrante delicto, but the two legislations differ in the scope of those methods. As an exception, the Mauritanian legislator did not make investigations mandatory except in specific felonies mentioned in Article 71 of the Penal Procedure Code as a matter of arrest.

مقدمة:

الجريمة كظاهرة اجتماعية، حتى وإن لم تكن قدرا محتوما في حياة الأفراد إلا أنها قدر محتوم في حياة الشعوب والأمم، وإن كان اعتبار مكافحة الجريمة واجبا مقدسا ملقى على عاتق السلطات المختصة التي تسهر على دعم الأمن في الجماعة فإن أنجع وسيلة لمعاقبة الجاني تكمن في الدعوى العمومية التي تباشر باسم المجتمع بواسطة النيابة العامة باعتبار الجريمة تلحق ضررا بالمجتمع المدني ككل.

وهذا لا يعني إقصاء المتضرر ومنعه من مباشرة حقه في التعويض، حيث مكّنه القانون من مقاضاة الجاني ومطالبته بالتعويض في الضرر الحاصل من جراء فعله الإجرامي.

ومن المبادئ السائدة في التشريعات الجنائية المعاصرة أنه "لا عقوبة بدون محاكمة" ومعنى ذلك أنه لا يجوز للدولة الالتجاء إلى تنفيذ العقاب مباشرة وإنما عليها أن تستصدر حكما قضائيا يكشف حقها ويقضي بنفاذه بعد ثبوته⁽¹¹⁰⁾.

فحق الدولة في العقاب يمر بعدة مراحل إجرائية تبتدئ بالبحث في الجرائم وجمع الأدلة وتنتهي بإصدار حكم إما بالبراءة أو بالإدانة وتنفيذ الحكم.

وبين الجريمة والعقوبة نجد جملة من الإجراءات التي تحدد نطاق الإدعاء الجنائي وتنظم مختلف المراحل الذي يجتازه حق الدولة في العقاب وهو ما يصطلح عليه "بالعقوبة الجنائية" التي تهدف بالأساس إلى حماية مصلحة الفرد وحماية مصلحة الجماعة⁽¹¹¹⁾.

وحماية هذه الأخيرة يتطلب بالضرورة ممثل أو ناطق باسم هذه الجماعة ومدافع عنها وهو ما يعرف بحماية الحق العام والذي تتولاه النيابة العامة عن طريق الدعوى العمومية.

فالدعوى في مفهومها العام هي السلطة التي يستمدّها الشخص من القانون للحصول من هيئة قضائية تابعة للدولة على الحق الذي يدّعي أنه له، وتبعاً لذلك فإن استرجاع أي حق مسلوب يدعيه أي شخص لا يمكن أن يستند إلى منطق القوة والأخذ بالثأر، بل يجب رفع الأمر إلى القضاء بوصفه الجهاز الرسمي الوحيد من أجهزة الدولة الذي يوفر طرق استرجاع الحقوق⁽¹¹²⁾.

1- عبد الفتاح مصطفى الصيفي: حق الدولة في العقاب: جامعة بيروت العربية 1971 ص 9

111 - Monia Ben Attia : La poursuite dans le procès pénal ; Mémoire DEA Sc crim ; Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 1988 p2

112- رضا خماسم: التعليق على أحكام م.ج. 1 في إقامة الدعوى العمومية ومباشرة التحقيق: منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2001 ص 33

فالدعوى العمومية هي وسيلة المجتمع لتوقيع العقاب على الجاني تمارسها باسمها النيابة العمومية.

وفق المفهوم المذكور أعلاه للدعوى عامة والدعوى العمومية خاصة، فإن القاضي لا يمكن أن يتعهد من تلقاء نفسه للنظر في قضايا الناس إلا متى رفعت إليه الدعوى. فهي شرط جوهري حتى تتمكن السلطة القضائية من ممارسة صلاحيتها. والقاضي الجزائي لا يمكن له البت في أي نزاع إلا متى تم إثارة الدعوى العمومية وتقديمها للقضاء للفصل فيها.

وقد جاء بالفصل 2 م إ ج ت والمادة 2 من ق إ ج م أن إثارة الدعوى العمومية وممارستها من اختصاص قضاة المحاكم والموظفون الذين أناطها القانون بعهدتهم، كما أضافت المادة 27 من ق إ ج م أن النيابة العامة تمارس الدعوى العمومية وتطلب تطبيق القانون وهي ممثلة لدى كل محكمة جزائية.

فالنيابة العمومية هي الجهاز القضائي المكلف بالدفاع عن مصالح المجتمع لدى الهيئات القضائية الجزية⁽¹¹³⁾ وذلك من خلال إثارة الدعوى العمومية⁽¹¹⁴⁾ وممارستها والسهر على تطبيق القانون

وتمتاز النيابة العمومية بمركز قانوني يختلف عن ما يتمتع به القضاء الجالس وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن سلطات النيابة العمومية في إثارة الدعوى العمومية (المبحث الأول) ثم التعرض في مرحلة لاحقة إلى الطرق المعتمدة من قبل النيابة للإثارة الدعوى العمومية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: سلطة النيابة العامة في إثارة الدعوى

النيابة العامة لا تقوم بالدور المنوط بعهدتها إلا من تاريخ علمها بالجريمة وهذا العلم قد يتخذ أشكال متعددة فقد يكون على شكل شكاية من المتضرر أو وشاية من الغير أو اكتشاف هذه جريمة بمناسبة القيام بأعمال بحث من طرف أعوان الضابطة العدلية⁽¹¹⁵⁾.

وبناء على ذلك فإن وكيل الجمهورية بمجرد علمه بفعل من شأنه أن يكون جريمة وقبل إثارة الدعوى العمومية يجب عليه أن يتأكد من شرعية التتبع (أ) عملاً بأحكام المادة 36 من ق إ ج م والفصل 30 من م إ ج ت يقدر مدى إمكانية إثارة الدعوى العمومية تأسيساً على مبدأ ملائمة التتبع (ب).

المطلب الأول- تقدير شرعية التتبع

أوكل المشرع للنيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية مهمة إثارة الدعوى العمومية وممارستها والسهر على تطبيق القانون⁽¹¹⁶⁾ فوكيل الجمهورية هو سيد الدعوى العمومية⁽¹¹⁷⁾ وبالتالي يكون عليه

1- J.FALLET : R P D P : op cit

-Bouguerra(M): Le ministère public en droit Tunisien: Organisation et attribution :mémoire de D.E.S Faculté de droit et de sciences politique et économique,Tunis, 1974.

2 - قرار تعقيبي جزائي عدد 1922 مؤرخ في 19 ديسمبر 1977 ن م ت ق ج عدد 1 لسنة 1977 ص 210 " الحكم من أجل جريمة لم تقع إثارتها من طرف النيابة العمومية موجب للنقض."

3- VITU : Le classement sans suite : R S C 1947 p 503

116- المادة 27 من ق إ ج م الفصل 20 م إ ج ت.

117 - Buisson(J) à cité que « Le procureur de la république, seul maître de l'action public » JCPP 1998

أن يتثبت من شرعية التتبع قبل إحالة الدعوى إلى المحاكم وذلك من خلال تقدير شرعية التتبع من حيث الأصل ومن حيث الشكل.

فوجود الجريمة في بعض الحالات غير كاف لإثارة الدعوى العمومية إذ يجب التأكد من قيام أركان الجريمة ووجود أدلة كافية للإدانة.

فبمجرد وقوع الجريمة يجب على وكيل الجمهورية التأكد من قيام أركانها والتي تستوجب أولا التأكد من توفر الركن الشرعي أي الوجود القانوني للجريمة، فلا جريمة بدون نص قانوني يحددها و يقر عقوبتها تأسيسا على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات⁽¹¹⁸⁾.

ويتربط عن هذا المبدأ أنه لا يمكن معاقبة شخص إلا إذا ارتكب فعل يعجره القانون ويضبط له عقوبة وأن يكون هذا النص القانوني نافذا وقت ارتكاب الجريمة. فمن واجب "قلم الإدعاء" أن يعين بدقة التهمة الموجهة للمشتبه فيه والنص القانوني المنطبق عليها⁽¹¹⁹⁾.

ثانياً التأكد من توفر الركن المادي باعتباره الفعل أو السلوك الذي يأمر القانون بتركه أو عدم القيام بما يأمر القانون بفعله⁽¹²⁰⁾. والمبدأ في القانون الجنائي أنه لا عقاب إلا من أجل جريمة تامة أدت إلى تحقيق نتيجة إجرامية إلا أن المشرع يعاقب على المحاولة بالنسبة للجنايات والجناح في الصور التي بنص عليها القانون⁽¹²¹⁾.

وأخيراً التأكد من الركن المعنوي حيث جاء بالفصل 37 من المجلة الجزائية التونسية أنه "لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا عدا الصور المقررة بوجه خاص بالقانون."

كما يجب على وكيل الجمهورية التأكد من توفر عناصر كافية للإدانة وقيام المسؤولية الجنائية للمشتبه فيه أي أن تتجمع لديه كل الأدلة التي تقنعه بوجهة هذا التتبع وأن يمتنع من إحالة شخص غير مقتنع بإدانته إذ لا فائدة ترجى من إشغال المحكمة بقضية يعرف وكيل الجمهورية مآلها سلفاً⁽¹²²⁾. فلوكيل الجمهورية الامتناع عن إثارة الدعوى العمومية إن رأى أن المصلحة العامة في ذلك تفرض عدم الإثارة كما في صورة عدم الرغبة في لفت انتباه الرأي العام لمثل هذه الجرائم على شرط أن لا تكون خطيرة.

والنيابة العامة لا يمكن لها إثارة الدعوى إلا متى كانت مختصة ترابيا حيث جاء بالمادة 35 من ق ج م "يمثل وكيل الجمهورية شخصيا أو بواسطة أحد نوابه النيابة العامة لدى محكمة الولاية ومحاكم الدرجة الأولى الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الولاية" ونفس النهج سلكه نظيره التونسي بالفصل 27 م.إ.ج "يتعهد بالتبوعات وكيل الجمهورية المنتصب بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بالمكان الذي به مقر المظنون فيه أو بمحل إقامته الأخير أو بالمكان الذي عثرفيه عليه."

ونظرا لتعدد الاختصاص فإنه يمكن أن ينشأ تنازع ايجابي حول الاختصاص بين وكلاء الجمهورية بالمحاكم الابتدائية المختلفة فقد يتعهد وكيل الجمهورية المنتصب بالمكان الذي ارتكب فيه

118- المادة 4 من ق ج م الفصل 13 من الدستور التونسي و الفصل 1 من المجلة الجزائية التونسية.

119- قرار تعقيبي عدد 2939 صادر في 28 جوان 1948 م ق ت 1963 "من الواجب على قلم الإدعاء وقاضي الإحالة أن يعينا بتدقيق التهمة الموجهة على المظنون فيه والنص القانوني المنطبق عليها."

120- فرج القصير : مرجع سابق ص 84 .

121- المادة 2 من ق ج م ولفصل 59 م ج ت.

5- البشير زهرة: النيابة العمومية: م ق ت العدد 3 مارس 1981 ص 14.

الجريمة وفي نفس الوقت قد يتعهد زميله المنتصب بالمكان الذي عثرفيه على المشتبه فيه فما هو الحل في هذه الصورة؟

في هذه الصورة يمكن القول بأن من تعهد أولاً هو الذي يكون له حق الاحتفاظ بملف القضية ومواصلة العمل فيها. وهذا ما كرسه المشرع التونسي في الفصل 16 م إ ج ت⁽¹²³⁾ أما بالنسبة لوكيل الجمهورية الذي رفعت يده عن القضية فإنه يجب عليه إحالة ما قام به من أبحاث إلى زميله الذي تعهد أولاً "فمن مصلحة الأمن العام أن لا يلغي الآثار والأدلة التي يؤتى بها إليه أو التي يستكشفها"⁽¹²⁴⁾

المطلب الثاني:- تقدير ملائمة التتبع

تتبنى الأنظمة الإجرائية المعاصرة مبدأ من مبدأين مبدأ شرعية التتبع أو مبدأ ملائمة التتبع و يعني الأول أن النيابة العامة تكون ملزمة بإثارة الدعوى العمومية إزاء كل الجريمة بلغها العلم بها⁽¹²⁵⁾ أما الثاني فيعني أنه للنيابة العمومية الاجتهاد في تقدير مدى وجاهة التتبع بما "يسمح بإفلات بعض الجرائم القابلة للمسائلة والثابتة بوجه كاف من أية إجراءات جنائية وذلك لبواعث لا شأن لها بالقانون"⁽¹²⁶⁾.

والقانون الموريتاني والتونسي اعتمدا مبدأ ملائمة التتبع على أن هذا المبدأ لا يجب الأخذ به على إطلاقه إذ أن المشرع أتبعه ببعض الاستثناءات.

ويقصد بمبدأ ملائمة التتبع أنه عند حدوث جريمة ما والعلم بها من قبل وكيل الجمهورية والتحقق من ثبوتها من الناحية القانونية فإنه على هذا الأخير القيام بتقدير ملائمة التتبع أي أن يختار بين إثارة الدعوى العمومية أو حفظ القضية وهو ما أكدته المادة 36 من ق إ ج م بقولها "يتلقى وكيل الجمهورية البلاغات والشكاوى والمحاضر ويتخذ في شأنها ما يراه ملائماً" وقد تبني المشرع التونسي نفس التوجه بالفصل 30 م إ ج الذي جاء فيه أن "وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه" وهو ما أكدته الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب حيث اعتبرت أن مبدأ ملائمة التتبع يكسب النيابة العمومية شرعية التحكم في مآل الدعوى الجزائية"⁽¹²⁷⁾.

وانطلاقاً من هذا الفصل نتبين أن قرار إثارة الدعوى العمومية من عدمها ليس مبنياً على الاعتباط أو التعسف⁽¹²⁸⁾ لأن هذا القرار لا يقع اتخاذه إلا بعد إجراء أبحاث بخصوص الجريمة المرتكبة هذا إلى جانب مراعاة كل الظروف الحافة بالجريمة. ففي بعض الحالات رغم توفر الأركان القانونية للجريمة وثبوت انتسابها للفاعل إلا أن وكيل الجمهورية يخير عدم الإثارة لانعدام مصلحة المجتمع في ذلك. فمصلحة المجتمع لا تتمثل بضرورة في تتبع كل الجناة خاصة وأن علم الجريمة قد

1- الفصل 16 م إ ج: إذا حدث أن تعهد مأمورون عديدون بقضية واحدة بقدّم من رفعت إليه القضية أولاً.

2- جان دوبلا: مختصر في شرح قانون المرافعات الجنائية: نقلاً عن محمد عبو مرجع سابق الذكر ص 67.

125- مريم ألفي: مبدأ ملائمة التتبع: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس 2004/2003.

126- محمود سمير عبد الفتاح: النيابة العمومية و سلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة: الدار الجامعية بيروت 1991 ص 147.

127- قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 3822.99 بتاريخ 26 أكتوبر 2000: فقه قضاء الدوائر المجتمعة 1961-2007: تونس 2008 ص 146.

128- البشير زهرة: النيابة العمومية: م ق ت مارس 1981 ص 10.

أثبت أن التصدي للظاهرة الإجرامية لا يتطلب بالضرورة اللجوء إلى الردع العام والردع الخاص بقدر ما يتطلب العمل على إصلاح المجرم بتفريده بالعقوبة و اتخاذ التدابير المناسبة لشخصيته⁽¹²⁹⁾.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا ما قرروا كيل الجمهورية حفظ القضية هل يمكن إثارتها من جديد؟ أي هل يحق للنياحة العمومية أن تتراجع في قرار الحفظ ؟

وضع المشرع مبدأ قانونيا مفاده أنه لا يجوز تتبع أو محاكمة شخص من أجل نفس الفعل مرتين هذا من جهة، من جهة أخرى فإن قرار الحفظ ليس عملا قضائيا فهو يتخذ من دون مرافعة ولا يخضع لأي طريقة من طرق الطعن ولا يكتسب حجية الأمر المقضي به وتبعاً لذلك يمكن القول أن قرار الحفظ ليس إلّا قرارا إداريا لا يقبل أي طعن فيه إلّا برفع الأمر إلى رؤساء وكيل الجمهورية ومن هنا إذا تراءى له أنه من الملائم تتبع نفس الشخص من أجل نفس الأفعال من جديد ؛ أن يتراجع في قرار الحفظ الذي أصدره⁽¹³⁰⁾ ويمكنه من باب أولى وأحرى أن يتراجع في صورة ظهور عناصر جديدة على أنه يشترط أن لا تكون الدعوى العمومية قد سقطت بمرور الزمن⁽¹³¹⁾.

لكن هل يمكن اعتبار استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة إثارة جديدة لدعوى العمومية؟ استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة هو الإجراء الذي يقع بمقتضاه العودة إلى الدعوى العمومية⁽¹³²⁾ مجددا وهو إجراء من إجراءات ممارسة الدعوى لا إثارتها فهو تمديد لدعوى سبق أن أثرت من النياحة العمومية وعرضت على التحقيق.

ويستنتج مما سبق عرضه أن النياحة العمومية مختصة بمبدئيا بإثارة الدعوى العمومية إلّا أنه وتفاديا لما قد يحصل من تعسف عند أعمال هذا المبدأ فإن المشرع أتبعه ببعض الاستثناءات التي توجب الإثارة أو تحول دونها.

من ذلك صدور أمر يقضي بالتتبع حيث تقتضي التبعية الإدارية تنفيذ المرسوم للأوامر الشرعية الصادرة عن رئيسه⁽¹³³⁾ وهي خاصية تتميز بها النياحة العمومية مقارنة بالقضاء الجالس والتي أكدت عليها المادة 27 من ق إ ج م والفصل 23 م إ ج ت⁽¹³⁴⁾ على أنه يجب الإشارة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف سواء تلقى تعليمات بإثارة الدعوى العمومية من طرف وزير العدل أو قرر ذلك من تلقاء نفسه فإنه " لا حق له في إقامة الدعوى العمومية لدى المحكمة الابتدائية، كما لا حق له في الإحالة على المحكمة أو التحقيق؛ أو الإحالة على حاكم المخالفات وإثما يعطي أوامره لوكيل الجمهورية الذي يتولى تنفيذها"⁽¹³⁵⁾.

129- محمد عبو : مرجع سابق ص105.

130- محمد عبو: مرجع سابق ص 108.

131- قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة : سابق الذكر: "إن قرار الحفظ من النياحة العمومية هو الامتناع مؤقت عن تحريك الدعوى الجزائية ... مما يجعله قرارا وقتيا غير قابل للطعن و فاقد للحجية القضائية ولا يحول دون استئناف التتبع من النياحة العمومية في غضون أجل و شروط الدعوى و متى برزت أدلة جديدة".

132- سليم المثلوثي: استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة: مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في العلوم الجنائية تونس 2004-2005 ص14.

133- مهدي بنحسونة : استقلالية النياحة العمومية: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية تونس 2003-2004 ص11.

134- الفصل 23 م إ ج " لوزير العدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها و أن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه..."

135 - البشير زهرة : مرجع سابق: ص 10.

وفي صورة تلقي وكيل الجمهورية لأمر بالتتبع من رئيسه فإنه لا يحق له حفظ القضية بل يكون ملزماً مبدئياً بالتتبع ومن ثمة إثارة الدعوى العمومية.

كما أن النيابة تكون مطالبة بالتتبع في صورة قيام المتضرر على مسؤوليته الشخصية حيث جاء في الفصل 36 م إ ج ت والمادة 75 من ق إ ج م أنه للمتضرر في صورة حفظ القضية من وكيل الجمهورية إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية على أن ذلك لا يكون إلا وفق شروط معينة ضبطها المشرعين التونسي والموريتاني على أنه في حالات أخرى تكون إثارة الدعوى العمومية معلقة على قيد إجرائي كصدور شكوى أو الحصول على إذن.

فالمبدأ يقتضي أن إثارة الدعوى العمومية لا يتوقف على وجود التشكي⁽¹³⁶⁾ على أن هذا المبدأ يشهد استثناء مؤسساً على اعتبارات شخصية لا يقع اعتمادها في أغلب الأحيان باعتبار أن حق المجني عليه في إثارة الدعوى العمومية لا يمثل فقط قيداً على مبدأ ملائمة التتبع الذي تمارسه السلطات المختصة من خلال الامتناع عن تقديم الشكوى وإنما تحدث عنصراً من التعسف في إثارة الدعوى العمومية لا يبرره سوى الحاجة الملحة إلى حماية المصالح الخاصة للمجني عليه⁽¹³⁷⁾. كما أنه يجب على النيابة العمومية في بعض الحالات الحصول على إذن من هيئة أو من سلطة معينة لإثارة الدعوى العمومية. والإذن هو الإجراء نصّت عليه بعض القوانين والمعاهدات الدولية الذي من خلاله تعبر بعض الجهات عن عدم معارضتها إثارة الدعوى العمومية ضد شخص يتبعها⁽¹³⁸⁾. فالحصانة التي يتمتع بها بعض الأشخاص تكون عائق أمام إثارة الدعوى العمومية. والحصانة قد تكون قضائية⁽¹³⁹⁾ أو برلمانية وهي التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين⁽¹⁴⁰⁾.

أما فيما يخص الحصانة الدبلوماسية فقد كرستها اتفاقية فيانا الموقعة في 18 أفريل 1961 و التي تمنح الحصانة القضائية لسائر الأعوان الدبلوماسيين والأعوان والإداريين والفنيين للسفارات بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم بما يحول دون تتبعهم من أجل أي جريمة يرتكبونها بما في ذلك المخالفات.

136- الفصل 3 م إ ج ت " فيما عدا الصور التي نص عليها القانون لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية على وجود التشكي كما لا يوقفها ولا يعلقها الرجوع في الشكاية أو في القيام بالحق الشخصي."

137- أحمد حسن الفقيه: قيود الدعوى العمومية: رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة علوم جنائية تونس 1998-1999 Boubaker Houssein-Eddine : L'immunité en droit pénale : mémoire D.E.A tunis 1997-1998- 138 Sauyel(J) : Les immunités judiciaires : R.S.C1953.

139- فصل 22 من قانون 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء و المجلس العلي للقضاء و النظام الأساسي للقضاة إذ لا يمكن بدون إذن من المجلس الأعلى للقضاء تتبع أي قاض من أجل جنائية أو جنحة أو سجنه إلا في حالة التلبس على أنه يقع إعلام المجلس الأعلى للقضاء فوراً.

140 - الفصل 27 من الدستور التونسي " لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة أما في حالة التلبس فإنه يمكن إيقافه و يعلم المجلس المعني حالاً على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس المعني ذلك."

- حسن المقي: الحصانة البرلمانية في الدستور التونسي: م ق ت عدد 1 جانفي 1970 ص 31-32.

المبحث الثاني: طرق الإثارة

إثارة الدعوى العمومية هو طرح القضية وعرضها على القضاء وهو ما يدعو إلى التساؤل عن كيفية هذا الطرح بعبارة أخرى ما هو الإجراء الذي من خلاله نتيبن أن الدعوى العمومية وقع إثارتها فعلا؟

إذا ما قررت النيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية فإنها يكون أمامها وسائل مختلفة لإثارة الدعوى ففي حالات تكون ملزمة بالقانون بإتباع طريقة معينة دون الأخرى فبعض الجرائم لا يجوز تتبعها إلا بالإحالة على قاضي التحقيق (المطلب الأول) في حين أنه في جرائم أخرى يقع الإحالة على محاكم القضاء مباشرة (المطلب الثاني).

المطلب الأول- الإحالة على التحقيق:

فتح بحث تحقيقي هو الإجراء الذي من خلاله تتم إثارة الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق⁽¹⁴¹⁾ وهو في التشريع التونسي وجوبي في الجنايات⁽¹⁴²⁾ اختياري في الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك⁽¹⁴³⁾ أما المشرع الموريتاني فقد عدل عن هذا الموقف في تعديل 2007 حيث لم يعد التحقيق لديه إلزاميا إلا في بعض الجنايات حسب مقتضيات المادة 71 من ق.ج.م والتي نصت على أن "التحقيق يكو إلزاميا في:

1" الجنايات المعاقبة عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو تلك التي تصل العقوبة فيها السجن ثلاثين (30) سنة ؛

2 الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث"

على أن التحقيق يصبح وجوبي عمليا إذ ما قررت النيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية ضد مجهول عملا بأحكام الفصل 31م.إ.ج.ت. و بمقتضى إصدار قرار فتح بحث فإن وكيل الجمهورية يتولى إثارة الدعوى العمومية وذلك بتعميد قاضي تحقيق.

وقرار فتح بحث يجب أن يستوفي جملة من الشروط الشكلية والموضوعية التي سكت المشرع عنها وهذا القرار يجب أن يكون مكتوبا فشرط الكتابة في قرار فتح بحث يتمشى ومبدأ تدوين أعمال التحقيق ووجوب تكوين ملف عن القضية.

فالتطبيعي أن تكون وثيقة التعهد أي قرار إجراء البحث مكتوبا هذا بالإضافة إلى أن الفصل 51 م.إ.ج.ت والمادة 72 من ق.ج.م يلزمان قاضي التحقيق بالبحث في حدود الأفعال المبيّنة بقرار إجراء البحث وهو ما يفترض إدراجها في وثيقة مكتوبة.

1- Merle et Vitu cité que « Le réquisitoire est l'acte par lequel le procureur de la république met l'action en mouvement devant le juge d'instruction. » op cit p 870.

2- الفصل 47 م.إ.ج.ت.

143- من أمثلة القوانين التي جعلت التحقيق وجوبي في غير الجنايات نذكر الفصل 45 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إذ جاء فيه أن المحامي المباشر المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أثناء القيام بأعمال مهنته أو بمناسبة يخال وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق.

كما يجب أن يكون قرار فتح البحث مؤرخ وممضي ذلك حتى يكون للملف الوجود القانوني و الحجية. فالإمضاء تنصيب وجوبي وشكلية أساسية حيث أن غياب الإمضاء يبطل هذا القرار وكذلك الأعمال التي بنيت عليه باعتبارها صادرة عن قاضي تحقيق غير متعهد.

كما أن تاريخ القرار يساعد على تحديد مسألة التقادم وانقطاعه باعتبار أن قرار إجراء البحث هو عمل تتبع تحرك به الدعوى العمومية وتنقطع به مدة التقادم.

كما يجب أن يتم تعيين قاضي التحقيق في وثيقة التعهد وهو شرط إجرائي وشكلية ضرورية يترتب عن غيابها بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية عليها.

وقد أسند المشرع هذه المهمة للنيابة العمومية إذ جاء بالفصل 49 م.إ.ج ت " إذا كان بالمحكمة عدّة حكام تحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل قضية الحاكم المكلف بالبحث فيها." هذا الفصل وإن ورد في شكل جملة شرطية مفادها أن الخيار يكون للنيابة في حالة ما إذا تواجد عدة قضاة تحقيق بنفس المحكمة، ممّا يعني انتفاء الخيار عند وجود قاضي تحقيق واحد⁽¹⁴⁴⁾.

وقرار البحث يجب أن يستوفي جملة من الشروط الموضوعية كتحديد الأفعال المراد التحقيق في شأنها وتحديد الوصف القانوني والنص القانوني المنطبق وتعيين الأشخاص المشتبه فيهمهم.

على أن هذه التنصيصات لا تعد وجوبية وبالرجوع إلى الفصل 51 م.إ.ج ت والمادة 71 من ق إ ج م فإنه يمكن الاقتصار على تحديد الأفعال فقط باعتبار أن القاعدة الإجرائية تقتضي أن يكون التعهد عينيا موضوعيا لقاضي التحقيق ويعني ذلك أن إعطاء وصف قانوني للأفعال أو تعيين الأشخاص المشتبه فيهم لا يعد ضروريا ولا يقيد قاضي التحقيق.

ولئن كان القضاء الواقف هو الجهاز الأصلي المكلف بإثارة الدعوى العمومية بدون منازع على أن ذلك لا يعني إقصاء القضاء الجالس من حق إثارة الدعوى العمومية.

📄 -المطلب الثاني - الإحالة على المحاكمة

إذا قررت النيابة العمومية إحالة شخص على قاضي الناحية أو على المجلس الجنائي بالمحكمة الابتدائية التابع لها بالنسبة للتشريع التونسي، أو على الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية أو على المحكمة الجنائية بالنسبة للقانون الموريتاني فإن العمل القضائي جرى أن يسجل وكيل الجمهورية قرار إحالة إما على محضر البحث نفسه الذي قدمته له الشرطة أو سائر أجهزة الأمن المختصة الأخرى أو على ورقة مستقلة⁽¹⁴⁵⁾.

ولئن لم يخص المشرع قرار الإحالة بشكليات معينة إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة احترام بعض الشروط إذ يجب أن يتضمن قرار الإحالة اسم الشخص المحال، بيان الأفعال المنسوبة إليه، تاريخ قرار الإحالة وفي الأخير توقيع وكيل الجمهورية.

ويقع تسليم قرار الإحالة إلى كتابة المحكمة التي تتولى استدعاء المعني بالأمر وذلك بإحدى طريقتين إما توجيه استدعاء لمن تمت إحالته وهي الطريقة الإدارية أو بواسطة عدل منفذ.

144- سلمى خمّام: مرجع سابق ص 43.

145- رضا خمّام: مرجع سابق ص 60-61.

على أن الواقع جرى في تونس على إتباع الطريقة الإدارية وكل استدعاء بطريقة أخرى يعتبر غير قانوني⁽¹⁴⁶⁾.

وعلى خلاف قرار الإحالة فالمشرع خص الاستدعاء بجملة من الشروط الشكلية، إذا نصّ الفصل 135م.إ.ج والمادة 511 و 512 من ق.إ.ج م على جملة من البيانات الضرورية التي يجب أن يتضمنها الاستدعاء كبيان الفعل الواقع من أجله التتبع والنص القانوني المنطبق عليه، بيان المحكمة المتعدهدة ومكان وساعة وتاريخ الجلسة حتى يتمكن المتهم من الحضور، صفة المستدعى أي هل تمّ استدعائه بوصفه متهما أو مسؤولا مدنيا أو شاهدا، اسم المكلف بالتبليغ وصفته وتاريخ التبليغ، هذا بالإضافة إلى ضرورة ذكر اسم ولقب المستدعي وعنوانه.

ويفترض أن يبلغ الاستدعاء إلى المستدعي نفسه. إلا أن الفصل 139 م.إ.ج ت والمادة 520 من ق.إ.ج م نصّا على أنه يمكن أن يسلم أيضا إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا.

ويجب على مبلغ الاستدعاء أن ينصّ على صفة الشخص الذي تسلّم الاستدعاء حتى تتمكن المحكمة من معرفة ما إذا كان يتجه وصف الحكم غيابيا أو معتبر حضوري في صورة عدم حضور المستدعى إذ عملا بالفصل 175 م.إ.ج ت يكون الحكم معتبرا حضوريا إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم و لم يحضر ويكون غيابيا إذا استدعى المتهم بصفة قانونية دون أن يبلغه شخصيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تشريعنا يختلف عن التشريع الفرنسي من حيث أنه لا يحثّ على الاجتهاد في إبلاغ الاستدعاء إلى المعني بالأمر نفسه ويفتقر إلى بعض وسائل التبليغ عند غياب هذا الأخير، فقد فرض الفصل 555م.إ.ج فرنسي على العون المبلغ للاستدعاء أن يقوم بكلّ المساعي للتوصل إلى تسليم الاستدعاء لشخص المستدعي نفسه. فالفصل 139 م.إ.ج لا يفرّق بين الاستدعاء للمستدعي نفسه أو لوكيله أو لخادمه أو لمن يكون ساكنا معه وهو من شأنه أن يؤثر سلبا على الاعتراض. كما أن الاستدعاء يجب أن يقع تسليمه قبل مدّة من اليوم المعين للحضور بالجلسة وذلك لتمكين المستدعي من الاستعداد للحضور في الموعد وإعداد دفاعه أو تكليف محام للدفاع عنه.

وقد أوجب الفصل 136 م.إ.ج ت أن يكون الأجل بين توجيه الاستدعاء واليوم المعين للحضور الجلسة ثلاثة أيام على الأقل، أمّا إذا كان المستدعي قاطنا خارج تراب الجمهورية فإن الفقرة الثانية من الفصل 136 م.إ.ج ت ترفع الأجل إلى ثلاثين يوم.

وبالنسبة للتشريع الموريتاني نصت المادة 513 من ق.إ.ج م على أنه "يجب ألا تقل الفترة بين تاريخ تسليم الاستدعاء للموجه إليه واليوم المحدد لحضوره في الجلسة عن :

- ثلاثة أيام إذا كان المستدعى يقطن في المكان الذي ستعقد فيه الجلسة

- ثمانية أيام إذا كان يقطن في نفس المقاطعة؛

- خمسة عشر يوما إذا كان يقطن في نفس الولاية أو ولاية محاذية لها؛

- شهر إذا كان يقطن في إفريقيا أو في أوروبا؛ - ثلاثة أشهر إذا كان يقطن في أي جزء آخر من

العالم".

146- قرار تعقيبي جزائي عدد 7966 مؤرخ في 12 أبريل 1971 .

لكن تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص في المادة الوالية أي المادة 514 من نفس القانون أن تلك الأجال يمكن أن تختصر بأمر مسبب من القاضي في حالة الاستعجال لكن شريطة أن تكون السرعة وأمن المواصلات تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي الاستدعاء على تعيين أجل للحضور مع الإشارة إلى أمر القاضي

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما جزاء الإخلال بهذه الشكليات؟

جاء بالفصل 199 م.إ.ج على أنه " تبطل كلّ الأعمال و الأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام والقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية. " وهو نفس التوجه الذي سلكه المشرع الموريتاني في المادة 169 من ق إ ج م.

وفضلا عما تقدم قد تكون الإحالة توا على معنى الفصلان 200 و 206 م.إ.ج ت حيث حوّل المشرع وكيل الجمهورية إمكانية إحالة المشتبه فيه توا على حاكم الناحية إن كان بحالة سكر أو عجز عن التعريف بنفسه ، أو على المحكمة الابتدائية بعد استنطاق بسيط في صورة الجريمة المتلبس بها، وهو نفس التوجه الذي كرسه المشرع الموريتاني انطلاقا من المادة 551 من ق إ ج م

الخاتمة:

يستنتج مما سبق عرضه أن المشرع الموريتاني والتونسي وأن اتفقا بخصوص دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتبنيهما معا لمبدأ ملائمة التتبع، إلا أن طرق إثارة الدعوى العمومية في التشريع التونسي تختلف نسبيا عنها في التشريع الموريتاني ذلك أنه بالنسبة للتشريع التونسي لا يمكن إحالة الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة توصف بأنها جنائية إلا بعد المرور بطور التحقيق أما بخصوص الدعاوى الناشئة عن جنح أو مخالفات فإن مرورها بطور التحقيق يبقى خاضعا لإرادة النيابة العامة ما لم تقم بحفظ الدعوى فإن قامت بحفظها صح للمتضرر تحريك دعواه أمام قاضي التحقيق وفق شروط معينة.

أما بالنسبة للمشرع الموريتاني فإن مرور الدعوى بطور التحقيق يبقى اختياريًا في المخالفات وفي الجنح وفي الجنايات إلا ما تم استثناءه بموجب المادة 71 من ق إ ج م التي استثنت عدة جنايات تم تحدها حصرا فضلا عن الجنايات التي ترتكب من طرف الأحداث حيث أبقى المشرع التحقيق فيها إلزاميا.

قائمة المراجع والمصادر:

- عبد الفتاح مصطفى الصيفي: حق الدولة في العقاب: جامعة بيروت العربية 1971.
- فرج القصير: القانون الجنائي العام : مركز النشر الجامعي بتونس 2006
- رضا خماخم: التعليق على أحكام م إ ج ج 1 في إقامة الدعوى العمومية ومباشرة التحقيق: منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2001.
- رضا خماخم العدالة الجزائية في تونس : منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية تونس 1997.
- البشير زهرة: النيابة العمومية: م ق ت العدد 3 مارس 1981.

- محمود سمير عبد الفتاح: النيابة العمومية و سلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، الدارالجامعية بيروت 1991.
- مريم ألفي: مبدأ ملائمة التتبع : مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس 2003/2004
- سليم المثلوثي: استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في العلوم الجنائية تونس 2004-2005
- مهدي بنحسونة، استقلالية النيابة العمومية: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية تونس 2003-2004.
- أحمد حسن الفقيه: قيود الدعوى العمومية: رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة علوم جنائية تونس 1998-1999
- Boubaker Housseem-Eddine : L'immunité en droit pénale : mémoire D.E.A tunis 1997-1998
- Sauyel(J) :Les immunités judiciaires :R.S.C1953
- Merle et Vitu cité que « Le réquisitoire est l'acte par lequel le procureur de la république met l'action en mouvement devant le juge d'instruction. » op cit
- Monia Ben Attia : La poursuite dans le procès pénal ; Mémoire DEA Sc crim ; Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 1988.
- Bouguerra(M): Le ministère public en droit Tunisien: Organisation et attribution :mémoire de D.E.S Faculté de droit et de sciences politique et économique,Tunis, 1974.
- VITU : Le classement sans suite : R S C 1947
- Buisson(J) à cité que « Le prcureur de la république, seul maitre de l'action public » JCPP 1998
- الأمر القانوني 83 – 163 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007 - 036
- مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.